

詐欺罪の実行の着手に関する次の【事例】及び【判旨】について後記Aからオまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

甲及び乙は、既に100万円の詐欺被害に遭っていたVに対し、警察官に成り済まして電話し、犯人検挙及び被害回復のために必要と誤信させ、Vに預金を払い戻させた上、警察官に成り済ました甲がV宅に赴き、捜査に必要であるから現金を預かるとのうそを言ってVから現金をだまし取ることを計画した（以下「本件計画」という。）。その上で、乙は、本件計画に従ってVに電話し、捜査に必要であるから預金を全部払い戻してほしいというそを言い、これを信じたVが預金を払い戻して帰宅すると、その約1時間後に再び乙がVに電話し、間もなく警察官がV宅に行くとうそを言った。しかし、甲は、V宅に到着する直前、警察官に逮捕された。

【判旨】

1回目と2回目の電話における各うそ（以下「本件うそ」という。）を述べた行為は、本件計画の一環として行われたものであり、本件うその内容は、本件計画上、Vが現金を交付するか否かを判断する前提となるよう予定された事項に係る重要なものであった。そして、このように段階を踏んでうそを重ねながら現金を交付させるための犯行計画の下において述べられた本件うそには、Vに現金の交付を求める行為に直接つながるうそが含まれており、既に100万円の詐欺被害に遭っていたVに対し、本件うそを真実であると誤信させることは、Vにおいて、間もなくV宅を訪問しようとしていた甲の求めに応じて即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるものといえ、本件うそを一連のものとしてVに対して述べた段階において、Vに現金の交付を求める文言を述べていないとしても、詐欺罪の実行の着手があったと認められる。

【記述】

- ア. 【判旨】は、犯罪の実行行為自体ではなく、実行行為に密接で、被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為を開始することによっても未遂罪が成立し得るとする立場と矛盾しない。
- イ. 【判旨】は、本件うそとその後に予定されたうそを述べる行為全体を詐欺罪の構成要件である「人を欺く行為」と解した上で、一連の実行行為の開始があることから未遂犯の成立を認める立場と矛盾する。
- ウ. 【判旨】は、実行の着手を判断する際に行行為者の犯行計画を考慮する立場を前提としている。
- エ. 【判旨】は、1回目の電話では実行の着手を認めず、2回目の電話で実行の着手が認められると明示している。
- オ. 【判旨】は、詐欺罪の実行の着手が認められるためには必ずしも財物交付要求行為が必要ないとの立場を前提としている。

No133

R4-3

詐欺罪の実行の着手

正解

ア 1 イ 2 ウ 1 エ 2 オ 1

正答率

74%

本問の【事例】及び【判旨】は、最判平 30.3.22（百選 I 63 事件）を題材としたものである。

ア 正しい

最判平 30.3.22（百選 I 63 事件）により、本記述は正しい。

【判旨】は、「本件うそを一連のものとしてVに対して述べた段階」で詐欺の実行の着手を認めているが、その理論構成として、本件うそを述べる行為は詐欺罪の実行行為自体ではないが、実行行為に密接で、被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為であり、その行為を開始することによって未遂罪が成立し得るとの立場（肢ア）に立っているのか、それとも、本件うそとその後に予定されたうそを述べる行為全体を詐欺罪の構成要件である「人を欺く行為」と解した上で、一連の実行行為の開始があることから未遂犯の成立を認める立場（肢イ）に立っているのかは明らかではない。この点については、いずれの立場に立ったとしても、本件うそを一連のものとして述べた段階において実行の着手を肯定できるため、【判旨】ではその理論構成が明示されなかったと評価されている。もっとも、同判例の山口裁判官補足意見は、最決平 16.3.22（百選 I 64 事件）を引用し、「犯罪の実行行為自体ではなくとも、実行行為に密接であって、被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為に着手することによっても未遂罪は成立し得る」として本記述と同様の考え方を示しており、その上で、「本件事案においては、1 回目の電話の時点で未遂罪が成立し得るかどうかはともかく、2 回目の電話によって、詐欺の実行行為に密接な行為がなされたと明らかにいえ、詐欺未遂罪の成立を肯定することができる」としている。したがって、【判旨】は、本記述の立場と矛盾しないといえる。

イ 誤っている

本記述は、【判旨】は、本件うそとその後に予定されたうそを述べる行為全体を詐欺罪の構成要件である「人を欺く行為」と解した上で、一連の実行行為の開始があることから未遂犯の成立を認める立場と矛盾するとしている点で、誤っている。

【判旨】は、「本件うそを一連のものとしてVに対して述べた段階」で詐欺の実行の着手を認めているが、その理論構成として、本件うそを述べる行為は詐欺罪の実行行為自体ではないが、実行行為に密接で、被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為であり、その行為を開始することによって未遂罪が成立し得るとの立場（肢ア）に立っているのか、それとも、本件うそとその後には予定されたうそを述べる行為全体を詐欺罪の構成要件である「人を欺く行為」と解した上で、一連の実行行為の開始があることから未遂犯の成立を認める立場（肢イ）に立っているのかは明らかではない。この点については、いずれの立場に立ったとしても、本件うそを一連のものとして述べた段階において実行の着手を肯定できるため、【判旨】ではその理論構成が明示されなかったと評価されている。したがって、【判旨】は、本記述の立場と矛盾しないといえる。

ウ 正しい

最判平 30.3.22（百選 I 63 事件）により、本記述は正しい。

実行の着手が認められるために必要とされる危険性を判断する際に、行為者の主観、犯行計画を考慮できることは判例上確立されているとされる。【判旨】も、本件うそを述べた行為は、「本件計画の一環」として行われたこと、また、本件うその内容は、「本件計画」上、Vが現金を交付するかどうかを判断する前提となるよう予定された事項に係る重要なものであったことなどを踏まえて、詐欺罪の実行の着手を認めている。したがって、【判旨】は、実行の着手判断する際に行為者の犯行計画を考慮する立場を前提としているといえる。

エ 誤っている

本記述は、【判旨】は、1回目の電話では実行の着手を認めず、2回目の電話で実行の着手が認められると明示しているとしている点で、誤っている。

最判平 30.3.22 の山口裁判官補足意見においては、本件事案において詐欺未遂罪の成立が認められるためには、2回目の電話（間もなく警察官が被害者宅を訪問することを予告する内容）によって、現金を交付する危険性が著しく高まり、詐欺の実行行為に密接な行為がなされたと明らかにいえるとして、2回目の電話の重要性が説かれているが、同判例の法廷意見は、【判旨】のように、1回目及び2回目の電話によって述べられた本件うそを一連のものとして詐欺罪の実行の着手の有無を判断するにとどまっている。したがって、【判旨】は、1回目の電話では実行の着手を認めず、2回目の電話で実行の着手が認められるとは明示していない。

オ 正しい

最判平 30.3.22（百選 I 63 事件）により、本記述は正しい。

【事例】では、警察官に成り済ました甲がV宅に到着する直前、警察官に逮捕されているところ、【判旨】は、「本件うそを一連のものとしてVに対して述べた段階において、Vに現金の交付を求める文言を述べていないとしても、詐欺罪の実行の着手があったと認められる」としている。したがって、【判旨】は、詐欺罪の実行の着手が認められるためには必ずしも財物交付要求行為が必要ないとの立場を前提にしているといえる。